

1505997-36.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, não se podendo, ainda, ignorar a dinâmica relatada pelos guardas civis, que avistaram o acusado em local já conhecido pela venda de drogas.

Se isso não bastasse, o acusado confessou espontaneamente que realizava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505997-36.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505997-36.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUTIERREZ MARTINIANO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Gutierrez Martiniano foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua dos Girassóis, altura do numeral 141, Jardim Ypê Pinheiros, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de uma praça pública, de um campo de futebol, dos estabelecimentos de ensino "EMEF Pref. Carlos Franco de Faria", "Centro Educacional Ernest Mahle", "CEI Clotilde Miachon Bueno" e da Unidade Básica de Saúde "Eitel Falsetti", trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 31 microtubos contendo cocaína, pesando 20 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado (fls. 115), apresentou defesa prévia (fls. 107/109) e a denúncia foi recebida aos 27 de abril de 2022 pela decisão de fls. 110/111.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

A representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da lei antidrogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 15); pelo laudo pericial do local (fls. 67/71); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 64/66) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal João Batista Anselmo disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido ponto de venda de drogas. Informa que já abordou o acusado em diversas ocasiões. Na data do fato, o acusado demonstrou nervosismo ao ver a viatura. Em razão disso, ele foi abordado e, em revista pessoal, no bolso de sua bermuda, foram localizados 31 pinos de substância branca, aparentando ser cocaína, além da quantia de R\$ 10,00. O acusado confessou que estava no local para a prática de tráfico.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Henrique da Silva, que confirmou a abordagem e a apreensão de 31 porções de cocaína, além de dez reais. O acusado afirmou que as porções se destinavam à comercialização. Informa que já havia abordado o acusado, mas nada ilícito apreendido.

Em solo policial, o acusado Gutierrez Martiniano disse que estava portando drogas para a venda e que tinha acabado de iniciar o turno. Tinha cocaína e vendeu apenas um pino, razão pela qual tinha a quantia de dez reais consigo (fls. 05).

Em juízo, o acusado disse que os fatos são verdadeiros e que as porções apreendidas se destinavam à comercialização. Afirma que o dinheiro apreendido era produto da venda de uma porção de cocaína.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente comprovados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como a droga estava embalada, características típicas do tráfico em larga escala, não se podendo, ainda, ignorar a dinâmica relatada pelos guardas civis, que avistaram o acusado em local já conhecido pela venda de drogas.

Se isso não bastasse, o acusado confessou espontaneamente que realizava a comercialização de drogas e que todo o entorpecente apreendido lhe pertencia e se destinava à venda.

Desse modo, inegável que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Nem se diga que o acusado praticava o tráfico de drogas para sustentar seu vício, pois não há prova nenhuma que indique tratar-se de usuário contumaz, apenas a sua

alegação.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, pois ostenta maus antecedentes (fls. 148/149), de modo que majoro a pena-base e fixo pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

A esse respeito, há que se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condenações relativas a fatos ocorridos em data anterior à do crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorra em data posterior, poderão ser utilizadas para majorar a pena-base. A esse respeito:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. 2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance 8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o início da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas como desfavoráveis. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 87.487/SP, Rel. o Ministro OG FERNANDES, 6ª Turma, DJe 13/08/2012; negrito não consta no original)

Em segunda fase, estão presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, de modo que a pena torna ao mínimo legal.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 67/71) revela que os fatos ocorreram existem estabelecimentos de ensino e unidade básica de saúde, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da

escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois o acusado ostenta condenação definitiva por prática idêntica à apurada nos presentes autos e que configura maus antecedentes, o que impossibilita a incidência da benesse.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Gutierrez Martiniano à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que ostenta maus antecedentes, tratando-se de outra condenação definitiva pelo crime de tráfico de droga, o que revela que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois declaradamente produto da comercialização de drogas.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 30 de junho de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA